

<제8장 청구의 병합과 소의 변경.제2절 소의 변경>

I. 소의 변경의 의의

1. 개념

- 소의 변경이란 소송 계속 중 원고가 청구의 기초를 동일하게 유지하면서 종래의 청구 즉 구소(舊訴)를 새로운 청구 즉 신소(新訴)로 교환하거나 추가하는 행위를 말한다. 행정소송에서는 행정소송법 제21조·제22조의 특별 규정과 함께, 특별한 규정이 없는 경우 민사소송법 제262조의 일반 규정을 준용하여 이루어진다. 이 제도는 소송 절차의 중복을 피하고 원고의 권리 구제를 실질적으로 보장하기 위한 소송법적 기술이다.

2. 취지

- 소의 변경 제도의 주된 취지는 소송 경제의 도모와 원고의 권리 구제 실효성 확보이다. 원고가 소송 과정에서 자신의 청구를 수정하거나 보완할 수 있도록 허용함으로써 심리의 중복을 피하고, 특히 행정소송의 경우 복잡한 소송 종류 중에서 구제 목적에 맞는 소송을 정확하게 선택하는 것이 어려울 때 소 변경을 통해 적절한 구제 기능을 유지하도록 돕는다. 즉, 소송 종류를 잘못 선택한 경우에도 소송 절차를 처음부터 다시 시작할 필요 없이 동일한 소송 계속의 효과를 유지하면서 청구를 바로잡을 수 있게 한다.

II. 「행정소송법」에 의한 소의 변경

1. 소송 종류 변경을 위한 소의 변경[행소법 제21조]

(1) 정의

- 소송 종류 변경을 위한 소의 변경은 취소소송을 당사자소송 또는 취소소송 외의 항고소송(무효등 확인소송, 부작위위법확인소송)으로 변경하는 것을 원고의 신청에 의해 법원의 허가를 받아 허용하는 제도이다.

(2) 내용 및 요건

- 이 제도는 행정소송 종류 간에 청구의 기초의 동일성을 전제로 하여 소의 변경을 통해 행정구제 기능을 강화하려는 행정소송법의 특칙이다. 소의 변경을 위해서는 청구의 기초에 변경이 없어야 하고, 사실심의 변론종결 시까지 신청해야 하며, 법원이 소 변경이 상당하다고 인정하여 허가를 해야 한다. 또한, 변경되는 신소는 제소기간 등 적법한 제소 요건을 갖추어야 하는데, 법원은 허가 결정을 할 때 구소가 제기된 때에 신소가 제기된 것으로 보아 제소기간 준수 여부를 판단한다. 피고를 달리하게 될 때에는 새로이 피고로 될 자의 의견을 들어야 한다.

(3) 효과

- 소의 변경이 허가되면 구소는 취하되고 신소가 그 자리를 차지하게 되며, 소송은 구소가 제기된 때에 신소가 제기된 것으로 보아 소송 계속의 효과가 소급하여 발생한다.

2. 처분변경으로 인한 소의 변경[행소법 제22조]

(1) 정의

- 처분변경으로 인한 소의 변경은 소송의 대상인 처분이 소 제기 후 행정청에 의해 변경된 경우, 원고가 변경된 처분을 대상으로 청구의 취지 또는 원인의 변경을 신청하여 법원의 허가를 받는 제도이다.

(2) 취지 및 요건

- 이 제도는 행정청의 처분 변경에 대응하여 원고가 다시 새로운 처분에 대해 소를 제기해야 하는 번거로움을 피하고, 새로운 처분에 대한 제소기간 준수의 어려움을 해소하여 원고를 보호하려는 취지에서 마련되었다. 원고는 처분의 변경이 있음을 안 날로부터 60일 이내에 소의 변경을 신청해야 한다. 다만, 변경되는 청구는 종전 처분에 대한 취소소송의 제기로서 행정심판을 거치지 아니하고 제기된 경우의 요건을 갖춘 것으로 본다.

(3) 효과

- 이 소 변경이 허가되면 소송 계속의 효과는 처분이 변경된 시점이 아니라 당초 소를 제기한 때로 소급하며, 변경된 처분에 대한 소송 절차를 계속하여 진행할 수 있다.

III. 「민사소송법」에 의한 소의 변경

1. 문제점

- 행정소송법 제8조 제2항은 이 법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 민사소송법의 규정을 준용하도록 규정하고 있다. 따라서 민사소송법 제262조가 규정하는 청구의 교환적 또는 추가적 변경이 행정소송에도 준용되는지 문제가 된다. 특히 항고소송과 민사소송 간의 교환적 소 변경을 허용할 수 있는지 여부가 학설 및 판례상 주된 쟁점이 된다. 행정소송법 제21조가 항고소송 간 또는 항고소송과 당사자소송 간의 변경만을 특별히 규정하고 있기 때문이다.

2. 학설

- 항고소송과 민사소송 간의 교환적 소 변경 허용 여부에 대하여 학설은 다음과 같이 대립한다.

(1) 긍정설

- 행정구제의 확대와 원고의 소송 경제 측면을 고려하여, 청구의 기초의 동일성이 인정되는 한 민사소송법 제262조를 준용하여 항고소송과 민사소송 간의 교환적 변경도 허용해야 한다는 견해이다. 소 변경은 당사자의 권리 구제를 위한 보충적인 수단이므로 폭넓게 인정해야 한다는 논리이다.

(2) 부정설

- 행정소송과 민사소송은 공법 관계와 사법 관계를 그 대상으로 하며 소송 구조가 본질적으로 다르다는 점을 강조한다. 행정소송법 제21조가 소송 종류 변경을 특별히 규정한 것은 이에 한정되어야 하며, 민사소송법상의 일반 규정을 준용하여 소송의 종류 자체를 바꾸는 것은 허용되지 않는다는 견해이다. 이는 공법 관계의 특수성을 유지하려는 관점에 기초한다.

3. 판례

- 판례는 행정소송으로 제기해야 할 청구를 민사소송으로 잘못 제기하였다가 이후 행정소송(항고소송)으로 소 변경을 한 경우, 항고소송의 제소기간 준수 여부는 처음 소를 제기한 때를 기준으로 판단해야 한다고 보아 원고에게 유리한 입장을 취한다. 이는 오제기(誤提起)된 민사소송을 관할 법원으로 이송한 뒤 소 변경이 이루어진 사안에서 나타난 태도로, 원칙적으로 항고소송을 민사소송으로 변경하는 것이 허용되는지에 대한 명시적인 판단이라기보다는, 행정구제의 실효성 확보라는 행정소송의 특수성을 고려하여 오제기된 경우에 한하여 절차적 편의를 제공한 것으로 해석된다. 따라서 항고소송과 민사소송 간의 단순 교환적 소 변경은 여전히 제한적으로 해석될 여지가 크다.

4. 검토

- 행정소송법 제21조와 제22조가 소의 변경에 관한 특별 규정이므로, 이에 해당하지 않는 소 변경에 대해서는 민사소송법 제262조가 준용될 여지가 있다. 그러나 항고소송과 민사소송 간의 교환적 변경은 소송의 본질적 차이로 인해 원칙적으로는 부정설의 입장에서 제한적으로 해석함이 타당하다. 다

만, 판례의 태도처럼 소송경제와 행정구제 실효성 확보를 위해 오제기의 경우에 한해 예외적으로 구소 제기 시점을 기준으로 제소기간 준수 여부를 판단하는 등 유연한 해석이 필요하다. 이는 소의 변경 제도가 가지는 권리 구제 기능을 행정소송에서 극대화하려는 합리적인 노력으로 평가할 수 있다.

IV 결론

- 소의 변경은 행정소송에서 원고의 권리 구제를 실질적으로 보장하고 소송 경제를 도모하는 핵심적인 제도이다. 행정소송법은 소송 종류의 변경(제21조)과 처분 변경에 대한 대응(제22조)에 관한 특별 규정을 두어 행정소송의 특수성을 반영하고 있다. 특별 규정이 없는 경우 민사소송법이 준용되지만, 항고소송과 민사소송 간의 교환적 변경은 소송 본질의 차이로 인해 제한적으로 해석되는 것이 일반적이다. 법원은 소 변경 제도를 통해 제소기간 준수 문제 등을 해결함으로써 행정소송의 구제 기능을 강화하는 방향으로 제도를 운용한다.